

1500866-35.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... droga apreendida era destinada ao tráfico. Ao Estado-acusador incumbe demonstrar a configuração do tráfico, que não ocorre pelo simples fato dos réus terem comprado e estarem na posse de entorpecente. Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público comprovar que o entorpecente era destinado ao tráfico. Não fazendo esta prova, prevalece a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,

Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500866-35.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 18716214 -

DEL.SEC.ITAPETININGA, 3778/21/300 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 2172496 - DISE-

DEL.SEC.ITAPETININGA, 3778/21/300 - DISE- DEL.SEC.ITAPETININGA, 2172496/2021 -

DISE- DEL.SEC.ITAPETININGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIVAN BATISTA DOMINGUES

Aos 24 de março de 2022, às 16:15h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes a defensora pública, Dr(a). Mariela Moni Marins Tozetto, e o DD. Promotor de Justiça Dr. Célio Silva Castro Sobrinho. Ausente o acusado EDIVAN BATISTA DOMINGUES. Antes de iniciados os trabalhos pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM.

Juiz foi decretada a revelia do réu e em seguida colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa do réu. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: acha-se processado o acusado como incurso no artigo 33 da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvidos nos autos, tanto em juízo como em solo judicial, os policiais militares narraram toda dinâmica das diligências, desde o momento em que receberam informações que davam conta do tráfico praticado pelo acusado, até a efetiva localização e abordagem do agente. Afirmaram que tão logo notou a aproximação da viatura, o acusado tentou se evadir, mas foi detido e submetido à revista, ocasião em que com ele foi encontrado dinheiro e 22 microtubos plásticos contendo cocaína, embalados e prontos para mercancia clandestina. As palavras dos policiais revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição do agente público; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Dessa forma, patente a conduta atribuída ao réu, sendo certo que a quantidade da droga, já dividida em porções e em unidades embaladas e prontas para a mercancia clandestina, indica claramente que se destinavam, sim, ao tráfico, deitando por terra a versão por ele deduzida na seara policial no sentido de que toda droga seria destinada ao seu próprio uso, sendo certo que em juízo tornou-se revel, deixando de atender o chamado judicial, comportamento que não se adequa a quem pretende invocar condição de inocência. Noutros termos, as circunstâncias do fato, aliados às máximas de experiências, indicam de forma concludente que as drogas que o acusado possuía eram destinadas, sim, a ulterior entrega ao consumo de terceiros, e ainda que o acusado fosse usuário, tal por si só não elide o tráfico, pois é bastante corriqueiro nos dias atuais a prática do tráfico para sustento do próprio vício. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia. Dada a palavra à Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz: O Acusado responde por este juízo pela suposta prática de tráfico de entorpecentes. Após a regular tramitação do feito, foi colhido o depoimento das testemunhas. O réu foi intimado, não compareceu ao ato processual e teve sua revelia decretada. Finda a instrução, o i. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Sem razão, contudo. DA PROVA ORAL COLHIDA. A testemunha PM Sandro narrou que receberam informação via COPOM com descrição de pessoa de cor parda e vestindo shorts que estaria vendendo drogas na plataforma da rodoviária. Ao diligenciarem, visualizaram o réu. Na busca pessoal, foram localizados os pinos de cocaína e vinte e sete reais em dinheiro. O réu afirmou que as drogas eram destinadas ao próprio uso. No mesmo sentido, o depoimento da testemunha PM Serrano. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. Deve haver a absolvição da imputação de tráfico de entorpecentes, porque não há prova de traficância. Sobre a necessidade de prova segura da traficância, aplica-se o seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal: "O réu não tem o dever de demonstrar que a droga encontrada consigo seria utilizada apenas para consumo próprio. Cabe à acusação comprovar os elementos do tipo penal, ou seja, que a droga apreendida era destinada ao tráfico. Ao Estado-acusador incumbe demonstrar a configuração do tráfico, que não ocorre pelo simples fato dos réus terem comprado e estarem na posse de entorpecente. Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público comprovar que o entorpecente era destinado ao tráfico. Não fazendo esta prova, prevalece a versão do réu de que a droga era para consumo próprio". (STF. 1ª Turma. HC 107448/MG, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 18.6.2013 - Info 711). Não foi produzida, nestes autos, prova suficiente de que a droga apreendida se destinasse ao tráfico. Mesmo quando a droga é apreendida em

grande quantidade (o que não é o caso dos autos), não se pode condenar sem prova da traficância. Neste sentido: "Sendo grande a quantidade de tóxico apreendida, induz seu tráfico. Mas ninguém pode ser condenado por simples presunção, motivo por que para o reconhecimento do delito se exige prova segura e concludente da traficância" (TJSP, Ac. 35.505-3, rel. Silva Leme, RT 603/316). Ainda, é caso de absolvição diante da contaminação da prova. Conforme se verifica dos autos, não foi observada a incomunicabilidade entre as testemunhas de acusação, já que ambas estavam no mesmo ambiente. Percebe-se que além da fragilidade probatória, o rompimento de regra processual basilar que versa sobre a incomunicabilidade de testemunhas, o que também deve conduzir à absolvição do réu. Desta forma, conclui-se insuficiente a prova da acusação, sendo impositiva a absolvição. DOSIMETRIA. Superadas as teses de mérito e de desclassificação, devem ser observadas as seguintes questões no tocante à concretização da pena. Na primeira fase, a pena deve ser fixada no mínimo legal. Foi apreendido com o Autor apenas pouca quantidade de droga, substâncias que o réu faz uso. Desta forma, não estão previstas as circunstâncias de exasperação da pena base mencionadas no art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, incide a atenuante da idade do Acusado, que tinha somente dezoito anos na época dos fatos. Na terceira fase, deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Necessária a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu percentual máximo, eis que o acusado é primário, tem bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integram organização criminosa. "A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução da pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo" (STF, 2ª Turma, HC 103.225/RN, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 22/11/2011). Acerca da quantidade e qualidade da droga apreendida e a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, decidiu o STF que a: "Quantidade e qualidade da droga apreendida é circunstância que deve ser sopesada na primeira fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo impróprio invoca-la por ocasião da escolha do fator de redução previsto no §4º do art. 33, sob pena de bis in idem" (STF, 2ª Turma, RHC 111.440/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/05/2012). Sobre o percentual aplicável: "O juiz, no exercício de suas funções judicantes, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado, deve fundamentar a não aplicação do percentual de 2/3 de redução, sob pena de violação do art. 93, IX, da CF/88, uma vez que é direito subjetivo do réu a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, desde que preenchidos os requisitos previstos no referido parágrafo" (STJ, 5ª Turma, HC 115.473/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 02/02/2009. REGIME INICIAL e PENA ALTERNATIVA. Quanto ao regime inicial, nos termos do artigo 33 do Código Penal, requer seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena. Isso porque, a fixação de regime fechado como decorrência automática do disposto no artigo 2º da Lei n. 8.072/90 contraria o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Habeas Corpus nº 111.840, em sessão realizada no dia 27 de junho de 2012, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo ao cumprimento

da pena em regime inicialmente aberto. Destarte de rigor a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena. Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o artigo 44 foi considerado inconstitucional pelo E. STF (HC n. 97.256/RS), o que motivou a expedição da Resolução n. 05, de 2012, do Senado Federal, suspendendo, nos termos do art. 52, X, da CF a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de

direitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06” No mesmo sentido foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 596.603/SP. Diante do exposto, requer sejam acolhidas as teses defensivas, nos termos da fundamentação supra. Por fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente nos termos da lei. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: EDIVAN BATISTA DOMINGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 25 de junho de 2021, por volta das 13:20hrs, na Rua José de Almeida Carvalho n. 500, neste município, trazia consigo, para fins de tráfico, 22 porções de cocaína. O feito foi regularmente processado encerrando-se a instrução nesta data com alegações finais do MP e da Defesa. Eis, em síntese, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu no tocante à prática do delito de tráfico ilegal de entorpecentes. A materialidade restou incontroversa ante a apreensão da droga e o laudo acostado aos autos. O réu é revel. Os policiais declararam que receberam denúncia de que havia um indivíduo na rodoviária vendendo entorpecentes; que as características pessoais foram passadas; que no local reconheceram o réu e, ao ver a viatura ele tentou fugir; que foi detido e em seu poder, além de 27 reais em dinheiro, havia 22 porções de cocaína. Pois bem, finalizada a instrução, temos que o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu é responsável pela prática do delito; a assertiva é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito. A quantia de droga encontrada, as circunstâncias da prisão e a declarações do policial evidenciam a finalidade de tráfico. A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu. Vale citar: “Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas” (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288). Vale dizer que a lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Vale, ainda, mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos de policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: “nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesados em cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória.” (Ap.Crim. 103.701 TJSP). “ a simples condição de policial não torna a testemunha suspeita ou impedida” (STF – RT 68/64). “ não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. ” (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Por outro lado, considerando que o réu é tecnicamente primário, é possível reconhecer a favor dele a causa de diminuição de pena do art. 33 parág. 4º, o que será feito no momento processual adequado. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e CONDENO o réu EDIVAN BATISTA DOMINGUES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06. Ante a condenação, custas pelo réu, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita deferidos nos autos. Fica decretado o perdimento dos bens e objetos apreendidos nos termos da Lei de Tóxicos.

DOSIMETRIA DA PENA. Atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal, a saber: CINCO ANOS DE RECLUSÃO e multa de QUINHENTOS DIAS MULTA, cada qual no seu mínimo legal. Não existem circunstâncias agravantes. Presente uma atenuante decorrente da menoridade cuja consideração resta prejudicada em face da fixação da base em seu mínimo. Inexistem causas de aumento de pena. Presente uma causa de diminuição de pena, prevista no art. 33 parág. 4º da Lei 11.343/06, eis que o réu preenche os requisitos ali exigidos, diminuo em 2/3 a pena até agora calculada, chegando-se ao "quantum" de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA. Não havendo incidência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda torno DEFINITIVA A PENA DE UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Nos termos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE e MULTA DE DEZ DIAS MULTA. Ante a substituição retro operada, inviável a suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena para o caso de conversão, o REGIME ABERTO. O réu foi colocado em liberdade no decorrer do feito e tal situação deve subsistir. Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, providencie-se o necessário para efetivo cumprimento da sanção imposta, arquivando-se o feito com as cautelas devidas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA